HABEAS CORPUS Nº 1017077 - MS (2025/0246844-2)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE	:	LEYSIANE MACIEL DA CONCEICAO (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EMENTA

PENAL. *HABEAS CORPUS.* TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. ANÁLISE CONJUNTA DOS VETORES. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO.
Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* ajuizado em nome de **Leysiane Maciel da Conceicao**, condenada pelo crime de tráfico de drogas à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 444 dias-multa (Autos n. 0901474-44.2023.8.12.0008, da 1ª Vara Criminal da comarca de Corumbá/MS – sentença às fls. 215/221).

Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória (Apelação Criminal n. 0901474-44.2023.8.12.0008).

Documento eletrônico VDA52993144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 09/12/2025 às 20:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/12/2025 20:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f9c93b0-265a-4568-9af9-b99c539081bd

Alega-se que houve indevido *bis in idem* na dosimetria, pois a natureza da droga foi utilizada na primeira fase para aumentar a pena-base e a quantidade foi usada para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu mínimo legal.

Sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores determina que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como vetor judicial único, na primeira fase da dosimetria, não podendo ser cindidas para fins de dosimetria da pena.

Afirma que a paciente é primária, de bons antecedentes e mãe de criança menor de 12 anos, o que reforça a necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TJMS. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de redução, com o devido redimensionamento da pena, abrandamento do regime inicial e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

A liminar foi indeferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente desta Corte, no exercício da Presidência (fls. 349/350).

Informações prestadas às fls. 357/359 e 377/381.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do *writ* ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 390/395).

É o relatório.

Inicialmente, o presente *writ* é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022).

No entanto, constato **ilegalidade flagrante** que impõe a concessão da ordem de *habeas corpus* de ofício.

Sobre a individualização da pena, o Juízo sentenciante lançou os seguintes fundamentos (fls. 252/254 – grifo nosso):

Documento eletrônico VDA52993144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 09/12/2025 às 20:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/12/2025 20:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f9c93b0-265a-4568-9af9-b99c539081bd

[...]

Partindo do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais: **Culpabilidade**: evidente e em elevado grau de reprovabilidade, porque a ré cometeu o crime na presença de seu filho menor de idade. **Antecedentes**: em consulta aos autos, verifico que a ré é primária e não ostenta antecedentes desabonadores. **Conduta social**: nada há nos autos de revelador. **Personalidade**: não há nos autos a prova pericial necessária para se aferir de forma segura a personalidade do agente. **Motivos**: normal para o delito em apreço. **Circunstâncias**: as circunstâncias do crime legitimam a exasperação da pena, vez que a ré faria o transporte intermunicipal de drogas (de Corumbá/MS para Campo Grande-MS), revelando maior audácia e, portanto, maior gravidade na prática do delito. **Consequências**: não destoam da normalidade. **Comportamento da vítima:** o sujeito passivo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 é o Estado, que em nada contribuiu para a ação delituosa. **Natureza da Substância ou Produto**: tem-se que o efeito da cocaína "é devastador, pois, além de causar dependência, afeta o sistema nervoso central, deixando sequelas no sistema límbico (que comanda as emoções) e no córtex (responsável pelas funções psíquicas) o que pode ocasionar alucinações no usuário". Quantidade da Substância ou Produto: opta-se por aplicar a quantidade da droga apenas na terceira fase da dosimetria. **Pena base**: **Fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa**, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (art. 49, § 2º, CP c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Circunstâncias atenuantes/agravantes: Inexistem circunstâncias agravantes. **Milita em favor da ré as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea "d") e da menoridade de 21 anos à época dos fatos (CP, art. 65, inc. I). Assim, diminuo a pena base em 2/6 (dois sextos), perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei 11.343/06).**

Causas de diminuição e aumento: Ausentes causas de aumento da pena. Incide no caso em apreço a causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei n.º 11.343/2006), porquanto a ré preenche os requisitos legais. No tocante à fração a ser adotada, é de se destacar que, além da significativa quantidade de entorpecentes apreendidos (2,065 kg de cocaína), resta caracterizado o concurso eventual de pessoas, o que justifica uma maior reprovação do delito. Desta feita, **reduzo a pena fixada em 1/6 (um sexto), perfazendo o montante de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).**

Pena definitiva da ré: 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, calculados à razão de 1 /30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, § 2º c.c. art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Regime inicial de cumprimento da pena: nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, deverá a ré cumprir a pena privativa de liberdade em regime inicialmente semiaberto.

Deixo de considerar o tempo de prisão provisória para fins da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, na forma do art. 387, § 2º, do CPP, porque não há elementos suficientes para se aferir neste momento processual a possibilidade de progressão de regime (requisitos objetivos e subjetivos), deixando, assim, tal providência para o Juízo da Execução (art. 66, inc. III, alínea "c", da Lei n.º 7.210/84).

Substituição da pena: incabível ante a ausência dos requisitos legais (CP, art. 44) .

Documento eletrônico VDA52993144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 09/12/2025 às 20:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/12/2025 20:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f9c93b0-265a-4568-9af9-b99c539081bd

O Tribunal de origem assim se posicionou a respeito da dosimetria no julgamento da apelação (fls. 25/33 – grifo nosso):

> Pretensão de redução da pena base
>
> A defesa requer que a pena base seja reduzida para o mínimo legal.
>
> Aduz que o magistrado singular considerou a culpabilidade, as circunstâncias e a natureza da droga como circunstâncias desfavoráveis, fixando a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, no entanto, o fundamento utilizado para negativas as referidas moduladoras é inidôneo, de modo que devem ser neutralizadas, reduzindo a pena base para o mínimo legal.
>
> [...]
>
> Do excerto transcrito verifica-se que foram valoradas negativamente três moduladora, a saber: **culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza da droga**.
>
> Quanto a moduladora da culpabilidade, o magistrado assentou: evidente e em elevado grau de reprovabilidade, porque a ré cometeu o crime na presença de seu filho menor de idade.
>
> A circunstância judicial referente à culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, o grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento.
>
> Como ensina Ricardo Schmitt, para a aferição da culpabilidade do agente deve ser apontado “um plus de reprovação social de sua conduta (...) o que temos é a necessidade em se valorar o grau de dolo ou de culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade”. Ainda, “a culpabilidade deverá ser entendida como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, pois se trata de um plus de reprovação da conduta do agente, que deverá contar como fundamentação concreta, idônea e individualizada” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 12. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 129.) Ora, é certo que o fato da apelante ter cometido o delito na presença de seu filho menor é suficiente para acentuar a gravidade e reprovação da conduta, já que submeteu o menor a esta situação delitiva, justificando a negativação da moduladora da culpabilidade, devendo ser mantida.
>
> De outro vértice, no que tange às circunstâncias do crime, o sentenciante consignou que: “as circunstâncias do crime legitimam a exasperação da pena, vez que a ré faria o transporte intermunicipal de drogas (de Corumbá/MS para Campo Grande-MS), revelando maior audácia e, portanto, maior gravidade na prática do delito”.
>
> É cediço que as circunstâncias do crime são elementos que não integram a estrutura do tipo penal mas envolvem o delito.
>
> Ricardo Augusto Schmitt, quanto a esta moduladora, leciona que: *“trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros”* (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal condenatória, Teroria e prática. 5ª ed.. Salvador: JusPodivm, 2010, p.104).
>
> Ora, é certo que o fato da apelante ter intenção de efetuar o transporte interestadual do entorpecente, uma vez que não foi utilizado como causa de aumento do crime na terceira fase, é fundamento idôneo para negativar a referida moduladora, posto que acentua a gravidade da conduta, já que visando disseminar em distância ainda mais longa o crime de tráfico de drogas.
>
> Assim, a fundamentação utilizada pelo sentenciante é idônea, devendo ser mantida a negativação da moduladora das circunstâncias do crime.
>
> Por fim, no que tange à moduladora da natureza da droga, o sentenciante consignou: “tem-se que o efeito da cocaína "é devastador, pois, além de causar

Documento eletrônico VDA52993144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 09/12/2025 às 20:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/12/2025 20:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f9c93b0-265a-4568-9af9-b99c539081bd

dependência, afeta o sistema nervoso central, deixando sequelas no sistema límbico (que comanda as emoções) e no córtex (responsável pelas funções psíquicas) o que pode ocasionar alucinações no usuário."

É cediço que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena- base acima do mínimo legal.

No caso dos autos, o magistrado singular valorou negativamente a circunstância da natureza da droga, por se tratar de cocaína.

Ora, é certo que quanto a natureza do entorpecente, evidentemente, a característica do produto é fator preponderante, por conseguinte, no caso concreto, não caracteriza ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal, porque é certo que quanto mais nefastos forem os efeitos do narcótico, superior será a possibilidade de lesão à saúde pública, que é o bem jurídico protegido nos delitos de tráfico de entorpecentes, de maneira que, neste caso particular, trata-se de "cocaína", e sabe-se que a cocaína, acima da maconha, é uma substância que causa efeitos deletérios e possui alto poder viciante, e a quantidade não é ínfima, autorizando, portanto, a valoração negativa da referida moduladora, tal como feito na sentença, não merecendo reforma.

Pretensão de diminuição da pena intermediária ao mínimo legal

A apelante defende que lhe foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, assim, impõe-se a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

[...]

Como visto, realmente foram reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, no entanto a redução referente a elas já foi operada pelo sentenciante, em 1/6 pra cada uma, o que conduziu a pena para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, ou seja, 4 meses acima do mínimo legal.

A análise da pretensão da apelante de redução da pena abaixo do mínimo legal só se justificaria caso tivesse sido dado provimento ao tópico anterior, reduzindo a pena base ao mínimo legal, o que não ocorreu.

Assim, como a pena base não foi aplicada no mínimo legal e a fração de redução pelas atenuantes da confissão e menoridade foi devidamente aplicada, não há que se falar em reforma da pena intermediária.

Ressalto que, caso a pena base tivesse sido aplicada no mínimo legal a pretensão da apelante ainda assim não poderia ser atendida pois esbarraria na Súmula 231 do STJ, que impede a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Pretensão de modificação da fração de redução referente ao tráfico privilegiado

A defesa pugna para que seja aplicada a fração máxima, de 2/3, para redução da pena na terceira fase da dosimetria, pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, sustentando que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas para determinar o quantum a ser utilizado na causa de diminuição do tráfico privilegiado, e que apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e desde que não utilizadas para fixação da pena-base.

[...]

Como se sabe, não existe fórmula matemática estabelecida em lei para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, cabendo ao Magistrado, dentro dos parâmetros legais, analisar as peculiaridades de cada caso e estabelecer a fração mais justa e adequada à repreensão e prevenção do delito, considerando, sobretudo, a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

O patamar de redução deve variar entre o mínimo de 1/6 e o máximo de 2/3, sendo que a margem de discricionariedade posta ao Juiz é grande, de forma que a eleição do quantum a ser decotado exige fundamentação extraída de elementos concretos.

Documento eletrônico VDA52993144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 09/12/2025 às 20:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/12/2025 20:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f9c93b0-265a-4568-9af9-b99c539081bd

> Na busca do índice ideal deve-se considerar, com preponderância sobre as moduladoras previstas no artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos exatos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.
>
> Como visto, o sentenciante fundamentou a eleição da fração de 1/6 para redução decorrente do tráfico privilegiado, na quantidade significativa de entorpecente apreendido, 2,065 quilos de cocaína, e pela prática do traficância em concurso de agentes, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta, o que certamente justifica a aplicação da fração de 1/6.
>
> [...]
>
> No caso, **o juiz sentenciante utilizou a quantidade da droga apreendida apenas na terceira fase do cálculo da pena para modular a fração redutora referente ao tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06**.
>
> Assim, considerando que o magistrado de piso utilizou a quantidade da droga apreendida apenas em uma das etapas da dosimetria da pena, especificamente, na terceira fase, mantenho essa forma de cálculo.
>
> Por sua vez, **o patamar de redução de 1/6, obedeceu a proporcionalidade e razoabilidade, eis que se trata de quantidade significativa de cocaína**.
>
> Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que aplicou o percentual de 1 /6 de redução em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, não merecendo reforma neste tocante.
>
> [...]

Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, **a natureza e a quantidade de drogas constituem vetor judicial único (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e não podem ser cindidas**. A propósito: REsp n. 1.976.266/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/11/2022; e REsp n. 2.176.663/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 26/12/2024.

Além disso, não cabe a esta Corte Superior suplementar a fundamentação, com vistas a justificar o afastamento da minorante ou a modulação de sua fração.

Fixadas essas premissas, passo ao redimensionamento das penas do paciente.

Na primeira fase da dosimetria, em razão da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da natureza das drogas apreendidas, mantenho a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, aplicada a fração de 2/6 pelas instâncias ordinárias, a pena intermediária regride a 5 anos e 4 meses de reclusão, e 533 dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 **à fração de 2/3**. Assim, na ausência de causas de aumento, fica estabelecida a reprimenda definitiva do paciente em **1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão de reclusão**, e **178 dias-multa**, no valor unitário mínimo legal.

Documento eletrônico VDA52993144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 09/12/2025 às 20:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/12/2025 20:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f9c93b0-265a-4568-9af9-b99c539081bd

Mantenho o regime inicial **semiaberto** em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 2,065 kg de cocaína).

Pelos mesmos fundamentos, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Em face do exposto, **concedo parcialmente** a ordem para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em 2/3, fixando a pena em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 178 dias-multa.

Comunique-se com urgência.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 09 de dezembro de 2025.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA52993144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 09/12/2025 às 20:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/12/2025 20:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f9c93b0-265a-4568-9af9-b99c539081bd